

Capítulo I NOCIONES PRELIMINARES El derecho de la constitución

1. — El nombre de nuestra disciplina es “**derecho constitucional**”, al modo como, similarmente, se usan las expresiones “derecho civil”, “derecho penal”, “derecho laboral”, etc. O sea que nos estamos refiriendo a un sector, un ámbito, o un casillero, del mundo jurídico. A lo mejor la terminología “derecho constitucional” no nos tiene acostumbrados a pensar en profundidad lo que acá significa el sustantivo “derecho”, seguido del adjetivo “constitucional”, por lo que vale la pena dedicarle un párrafo. Hablar de “derecho constitucional” es tanto como hablar de “derecho de la constitución”, con lo que aludimos a que la **constitución tiene naturaleza jurídica. O que es “derecho”. Y decir que es “derecho” equivale a afirmar que la constitución manda, prohíbe, permite, obliga, vincula, tiene eso que se da en llamar fuerza normativa, o vigor normativo. No son consejos, no son directivas. Son normas jurídicas que describen lo que hay que hacer, lo que no se ha de hacer, lo que se puede hacer.**

2. — En síntesis, **en el “derecho de la constitución” hallamos derechos de las personas, de los grupos, de los sujetos colectivos, y deberes, tanto individuales como colectivos y, fundamentalmente, del propio estado o, si se prefiere, de los órganos que ejercen el poder del estado.**

3. — Vayamos ahora a otro vocabulario. Hemos mencionado el **mundo jurídico**, que es una realidad humana, social, política y jurídica. ¿Qué hay en ella? Hay **normas** (las de la constitución formal son normas escritas, pero hay otras normas que no están escritas, como las del derecho consuetudinario); hay **conductas humanas interrelacionadas de unos sujetos con otros; y hay valores. Las normas, las conductas y los valores son jurídicos, y componen las tres dimensiones del mundo jurídico: el orden normativo, el orden sociológico. y el orden axiológico (o dikelógico, si damos por cierto que dikelogía es ciencia de la justicia).**

4. — **Conviene destacar que la juridicidad a la que estamos refiriéndonos proviene de la relación necesaria que existe en el mundo jurídico entre éste y la justicia como valor, el mundo jurídico no es neutro al valor: siempre es justo o injusto, más justo o menos justo, según su proximidad o distancia con el valor justicia**

5. — Hay otros conceptos que hemos de tener presentes. **Cuando hablamos de derecho positivo, hemos de entender que hablamos de un derecho que está vigente, que funciona, que tiene efectividad; diríamos: tiene vigencia sociológica en y por las conductas humanas. Cuando hablamos de constitución formal aludimos a la que está escrita, a la que está codificada en su normativa escrita: y cuando hablamos de constitución material o real, nos referimos a la que funciona y se aplica, tanto con normas escritas como con normas no escritas; o sea, a la que podemos encontrar o describir en la **dimensión sociológica del mundo jurídico constitucional.****

6. — La materia o el **contenido** del derecho constitucional se desdobra así: a) un ámbito que se refiere al **modo o manera como se sitúan políticamente los hombres en el estado**, tanto en la relación del hombre **con el estado** como en las relaciones **con los demás hombres**; b) un ámbito referido al **poder**, a sus **órganos, sus funciones, sus competencias**, y las **relaciones de órganos y funciones**. Al primer ámbito se le suele apodar **parte dogmática** de la constitución. y al otro se lo denomina **parte orgánica**. Hay que tener muy presente que no son dos sectores comunicados, sino muy **entramados entre sí**, sin fronteras rígidas ni separaciones tajantes.

7. — A la **constitución escrita se la considera una “ley”: ley suprema, o superley**. Está reunida en un solo cuerpo de normas escritas, y se afirma que proviene en su origen de un poder constituyente. La constitución escrita que no logra o que pierde su efectividad aplicativa y, por ende, no tiene (en todo o en parte) vigencia sociológica, lleva a reconocer que ha perdido su supremacía, y que en su lugar funciona una constitución material distinta u opuesta (en todo o en parte).

La constitución formal. — El derecho constitucional formal se maneja con una constitución también formal. Si la pensamos en su tipo clásico de constitución escrita o codificada, podemos describirla conforme a las siguientes características: a) La constitución es una ley. b) Por ser la ley suprema, se la considera como super ley. c) Esa ley es escrita. d) La formulación escrita está codificada, cerrada, o reunida en un texto único y sistematizado. e) Por su origen, se diferencia de las leyes ordinarias o comunes en cuanto es producto de un poder constituyente que, también formalmente, aparece elaborándola. De este esquema deducimos que la constitución formal pone el acento fundamentalmente en el aspecto normativo.

La constitución material — El derecho constitucional material remite a la dimensión sociológica, y utiliza el concepto de constitución material, o real, que equivale también al de régimen político o sistema político. Si buscamos sinónimos, decimos que la constitución material es la constitución vigente y eficaz (derecho constitucional positivo) de un estado, “aquí” y “ahora” en tiempo presente. Una constitución es material cuando tiene vigencia sociológica, actualidad y positividad. La constitución material se atiene, fundamentalmente, al fenómeno de la vigencia sociológica, a diferencia de la formal que, primariamente, destaca la normatividad.

La fuerza normativa de la constitución. — La constitución formal o escrita es jurídica, es normativa, contiene normas jurídicas. Por eso cabe decir que es “derecho”: el derecho de la constitución. De esta juridicidad que se predica de todo el texto constitucional — incluido su preámbulo y sus disposiciones transitorias— se desprende la llamada fuerza normativa. La constitución posee en sí misma fuerza o vigor normativos, lo que significa que es exigible, obligatoria, aplicable y vinculante. Y lo es para todos, para los gobernantes y para los particulares.

La coincidencia, discrepancia u oposición entre la constitución formal y la constitución material — La constitución material puede coincidir con la constitución formal. Ello acontece cuando la constitución formal tiene vigencia sociológica, funciona, y se aplica. La constitución material puede no coincidir con la constitución formal en todo o en parte. Ello acontece cuando la constitución formal, total o parcialmente, no tiene vigencia sociológica, ni funciona, ni se aplica. Una constitución formal o parte de ella puede no tener vigencia actual porque la tuvo y la perdió; o puede no haberla adquirido nunca (todo ello por violación ejemplarizada o por desuso). Cuando la constitución formal, en todo o en parte, no tiene vigencia, hay siempre una constitución material vigente que es la constitución real que funciona y se aplica. Todo estado tiene su constitución material, porque está “constituido” u organizado de una manera determinada. En los estados que carecen de constitución formal, hay por ello, siempre y necesariamente, una constitución material.

8.— Las fuentes del derecho constitucional argentino se clasifican así:

a) Fuentes formales: a') normas codificadas en el texto de 1853-1860 con sus reformas de 1866, 1898, 1957 y 1994; a'') normas escritas que se hallan fuera del texto codificado, como son las leyes a las que por su materia o contenido cabe calificar como leyes "constitucionales"; por ej.: la ley de partidos políticos, de ministerios, de ciudadanía, de habeas corpus, de amparo, etc. a''') tratados internacionales, algunos con jerarquía igual a la de la constitución, y otros solamente superiores a las leyes; por ej., los que enumera el art. 75 inc. 22 de la constitución; el Acuerdo (o concordato) con la Santa Sede, de 1966; la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, etc.

b) Fuentes materiales (que dan origen a contenidos en la dimensión sociológica del derecho constitucional, o sea: en la constitución material); b') el derecho consuetudinario (costumbre); por ej., la que muestra que el congreso cumple todas sus competencias dictando leyes (o sea. con forma de ley); b'') el derecho espontáneo, que surge rápidamente de conductas que quedan propuestas como "modelo" para ser imitadas por otras similares en casos análogos y en poco tiempo; la diferencia con el derecho consuetudinario radica en el lapso que se requiere para crear el producto: el derecho consuetudinario necesita largo tiempo y muchas conductas similares; el derecho espontáneo no, y ello porque siempre hay una interconexión con el poder que acelera el surgimiento del producto; por ej., tiene origen el derecho espontáneo la mala praxis que desde la reforma de 1994 ha llevado a un abuso en el dictado de decretos de necesidad y urgencia, en violación al excepcional supuesto que habilita el art. 99 inc. 3º de la constitución; b''') el derecho judicial, o jurisprudencia, que generaliza espontáneamente a las sentencias más allá del caso en el que se dictan, principalmente cuando esas sentencias provienen de la Corte Suprema; por ej., la creación del amparo desde 1957 hasta la legislación de 1966 y 1967; la formulación de los contenidos del derecho de propiedad, o de la categoría de sentencias arbitrarias; b''') el derecho internacional consuetudinario o derecho de gentes, que a veces da origen, después, a su formulación por escrito en tratados internacionales.

c) Fuentes históricas, que se dividen así: c') fuentes doctrinarias o ideológicas, que son todas las que se relacionan con el complejo cultural de la constitución; c'') fuentes normativas, que son los textos o normas que funcionan como antecedente del articulado de la constitución; c''') fuentes instrumentales, que se resumen en el proceso político jurídico que funciona como génesis de la constitución.

Clasificación de las constituciones

9.— La clasificación de las constituciones abre un arco de numerosas categorías

Ejemplificando, podemos citar:

a) constitución escrita o codificada en un texto único;

b) **constitución dispersa**, que puede constar de algunas normas escritas dispersas y otras no escritas; o bien ser totalmente no escrita, o totalmente formada por normas escritas dispersas;

c) **constitución rígida**, que para su reforma exige un procedimiento diferente al de la legislación común;

d) **constitución flexible**, que puede reformarse por el mismo procedimiento de la legislación común;

e) **constitución pétrea**, es la constitución codificada que no puede reformarse, sea en algunos de sus contenidos, o en la totalidad de su normativa;

f) **constitución pactada**, cuando surge de un acuerdo o convenio;

g) **constitución otorgada**, cuando un órgano de poder la establece unilateralmente. Las categorías de constitución formal y material ya fueron mencionadas anteriormente. La tipología de la constitución argentina

10.— Un somero examen de la tipología de la constitución argentina arroja el siguiente resultado: a) El texto originario, histórico y fundacional data de 1853, como producto de la Convención Constituyente que ejerció el poder constituyente originario; b) ese texto se completó en 1860, cuando también en ejercicio del mismo poder constituyente originario se integró la provincia de Buenos Aires a las otras provincias preexistentes; c) la codificación articulada en la constitución de 1853-1860 planificó el régimen político con pretensión de continuidad futura, y volcó a su contenido todo cuanto hacían aconsejable los antecedentes que, al menos desde 1810 fueron perfilando el estilo cultural de nuestra sociedad; esta génesis permite afirmar que la constitución de 1853- 1860 participa, en ese sentido, del tipo tradicional - historicista, en cuanto plasmó y legitimó los caracteres fundamentales que se habían venido alineando en la comunidad social preexistente; d) hay suficiente base para sostener que, no por mera afición racionalista, sino por la mencionada tradición histórica, la constitución hizo suyos cuatro contenidos que cabe calificar como pétreos, en el sentido de que en tanto no se modifique la estructura social subyacente que les dio apoyo, no deben suprimirse, aunque pueden modificarse sin alterar su esencia; esos cuatro contenidos pétreos son: d') la democracia como forma estatal basada en la dignidad de la persona humana, y en el reconocimiento de su libertad y sus derechos; d'') el federalismo como forma estatal de descentralización territorial del poder; d''') la república como forma de gobierno opuesta a la monárquica; d'''')) la confesionalidad del estado como reconocimiento de la Iglesia Católica en cuanto persona de derecho público,

11. — La reforma constitucional de 1994, no obstante las numerosas enmiendas introducidas al texto, ha mantenido fidelidad y congruencia con la constitución originaria en su contenido esencial. Por ende, consideramos que subsiste, aunque ampliado a tenor de nuevas valoraciones y pretensiones sociales, el eje vertebral del primitivo sistema axiológico con sus principios, creencias, valores y derechos. Al ritmo del tiempo histórico, hay derechos nuevos y contenidos nuevos en derechos viejos, y hay un techo ideológico con añadiduras y actualizaciones que dan fisonomía a un régimen de constitucionalismo social o, si se prefiere, a un estilo de estado social y democrático de derecho.

12.— En la constitución hay **normas operativas** que son autosuficientes y autoaplicativas; y **hay normas programáticas**, que obligan a que se les dé desarrollo a través de otras normas y políticas que deben completarlas para que funcionen plenamente. Cuando los órganos de poder que tienen a su cargo ese deber de desarrollar las normas programáticas no lo cumplen, incurren en violación de la constitución por omisión, o sea, en omisión inconstitucional. En la medida de lo posible, los jueces deben dar aplicación a las normas programáticas en los procesos judiciales que tienen a su cargo, para suplir en sus sentencias aquellas omisiones que son obstáculo para el desarrollo de la programaticidad. De ese modo se recupera la supremacía de la constitución.

Las mutaciones constitucionales

13.— Las mutaciones constitucionales son cambios y transformaciones reales que se producen en la constitución material sin que el texto de la constitución escrita o formal se reforme o modifique. Cuando una de tales mutaciones implica deformación u oposición respecto de las normas de la constitución formal, la tal mutación es violatoria de la constitución y, por ende, inconstitucional.

El preámbulo

14. — El preámbulo de la constitución contiene y condensa las decisiones políticas fundamentales. En él se comprimen las pautas del régimen, los fines y objetivos, los valores y principios propugnados, el plan o programa del constituyente. El preámbulo comparte la juridicidad y la fuerza normativa de la constitución. Por eso, hay que conferirle aplicación. Podemos desglosarlo así: - a) Cuando alude a los "representantes del pueblo", da a entender que el pueblo o la sociedad es el titular del poder constituyente originario; - b) cuando añade "por voluntad y elección de las provincias..." reconoce la preexistencia histórica de las provincias que en 1853 y 1860 dieron origen a la constitución; c) cuando se refiere al "cumplimiento de pactos preexistentes", deja en claro que el poder constituyente ejercido por el pueblo de las provincias en 1853 y 1860 ha tenido base contractual o consensual en los instrumentos que fueron preparando, como antecedentes, la formación y el nacimiento del estado federal argentino; d) cuando enuncia seis fines que, a la vez, aparecen como bienes y valores, traza el lineamiento del proyecto político; esos seis fines son: _ constituir la unión nacional; _ afianzar la justicia; _ consolidar la paz interior; _ proveer a la defensa común; _ promover el bienestar general; _ asegurar los beneficios de la libertad.

15.— Todo lo que inicialmente había de hacerse de conformidad con los verbos y los fines recién citados, persiste y se mantiene actualizado como propuesta que, día a día, necesita y exige las respuestas que la circunstancia de cada tiempo y lugar hacen necesarias para que el preámbulo se cumpla. La interpretación y la integración constitucionales

16.— Cuando tenemos una constitución con normas escritas, interpretar esas normas es buscarles el sentido, o sea, lo que quieren significar. Pero, además, hay que interpretar las normas que están por debajo de la constitución para averiguar, al compararlas con la constitución, lo que quieren decir y el sentido que hay que darles. Cuando se interpretan las normas de la constitución en su propio plano, hablamos de interpretación "de" la constitución. Cuando se interpretan las normas que están por debajo de la constitución y se las compara con la constitución, hablamos de interpretación "desde" la constitución.

17. — La interpretación puede tener un fin de puro conocimiento por ej., cuando se estudia derecho constitucional, o un fin aplicativo práctico por ej., cuando los jueces han de resolver un caso dictando una sentencia en virtud de normas de la constitución. 18. — Cuando se hace interpretación, nunca se puede ir en contra de la voluntad histórica del autor de la constitución, pero se puede y se debe efectuar una interpretación dinámica que, sin descartar aquella voluntad, vaya buscando con criterio finalis sentido actualizado para cada momento y cada circunstancia.

19. — Cuando falta una norma en la constitución o en los planos que se sitúan por debajo de ella, hay que cubrir ese vacío, que suele apodarse laguna. Hay una carencia o ausencia de norma, y para salvar la omisión de norma hay que hacer una operación de relleno o cobertura, que se llama integración. En tanto la interpretación presupone que hay una norma a la cual se

interpreta, la integración da por cierto que falta una norma y que, para solucionar un caso determinado, hay que integrar el vacío elaborando, para ese caso, una norma.

20. — Aun así, la integración siempre exige también respetar la constitución, de modo que para elaborar la norma faltante y dar solución a un caso, esa norma que se fabrica como cobertura de la norma ausente, debe ser compatible con la constitución. Esto implica que hay que -a la vez- interpretar la constitución para ver si la norma fabricada como supletoria de la que falta está o no de acuerdo con la constitución. De no respetarse la constitución, la norma sustitutiva de la norma que falta haría incurrir en inconstitucionalidad a la decisión que para el caso se adoptara mediante integración.

21. — Tanto la interpretación como la integración son mecanismos que cobran un papel trascendente cuando los jueces ejercen el control de constitucionalidad. La interpretación y, en su caso, la integración, han de llevarse a cabo en el referido control no sólo cuando se va a declarar inconstitucional una norma, sino también cuando se desemboca en una declaración que reconoce a una norma como compatible con la constitución.

22. — Conviene dejar bien aclarado que los principios generales de la constitución -o los simples principios- y también los valores, son aplicables no solamente cuando por integración hay que cubrir un vacío normativo, sino a la vez, y mucho, cuando hay normas a las que dar interpretación. Es así porque principios y valores del sistema axiológico de la constitución dan luz para entender y saber cuál es el sentido de las normas existentes.